

1500414-21.2021.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... lícito - Natureza permanente do crime de tráfico de drogas - Justa e prévia causa demonstrada - Preliminar afastada. Tráfico de Drogas - Insuficiência probatória - Absolvição - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Condenação mantida. Segunda fase da dosimetria - Reincidência específica não possui tanto desvalor a ensejar maior incremento da pena - Majoração ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500414-21.2021.8.26.0637 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500414-21.2021.8.26.0637

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2088111/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 17080355 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 771/21/229 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2088111 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2088111 - 02º D.P. TUPÃ, 771/21/229 - 02º D.P. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO LUAN MOREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Pablo Luan Moreira, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.

11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 109/111).

Determinou-se o processamento (fls. 112)

A parte processada, devidamente notificada (fls. 136), apresentou resposta escrita (fls. 122/127). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 09 de Outubro de 2021 (fls.

143/145) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 196).

Em audiência ([TA]), foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação, uma em comum e outra pela defesa; ao final, a parte processada foi interrogada.

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade dos fatos e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu o reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar; a improcedência da ação penal (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2257842-55.2019.8.26.0000, da 3ª Vara Judicial da Comarca de Bebedouro – Rel. Des. REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, V.U., j. 25/01/2020), argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); em ordem sucessiva, a desclassificação para o disposto no art. 28, caput, da LD; na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (TA).

2. Fundamentação

2.1. Preliminar

A defesa do acusado busca o reconhecimento do constrangimento ilegal na abordagem do acusado, que resultaria na pretensa ilegalidade das provas por derivação, o famoso princípio dos frutos da árvore envenenada, cuja origem é atribuída à jurisprudência norte-americana (“The fruits of the poisonous tree”), doutrina esta que defende que todas as provas decorrentes de prova ilícita são contaminadas por este vício.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes DJe 8/10/2010).

O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. O crime de tráfico de drogas, na modalidade guardar ou ter em depósito possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

Isso porque, conforme relatado pelos policiais militares, a abordagem foi procedida mediante fundada suspeita pelo comportamento do acusado, havendo denúncias anteriores que o acusado estaria praticando o delito de tráfico de drogas, havendo denúncia específica que estaria praticando o delito naquele momento, tendo se deslocado até sua residência logo após visualizar a viatura policial.

Também é de se esperar que a informante Beatriz, companheira do acusado, prestasse declarações que de certa forma favoreciam o acusado, sendo declarado pelos policiais militares que o portão da residência se encontrava aberto e que foi franqueada a entrada.

Nesse sentido há precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Preliminar. Ilegalidade das provas decorrentes de invasão domiciliar. Flagrante configurado. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição ou desclassificação para porte de drogas visando consumo próprio. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais.

Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escoreta. Réu reincidente. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Regime inicial fechado mantido. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500063-88.2021.8.26.0559; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2022; Data de Registro: 20/06/2022) Preliminar de nulidade - Violação de domicílio - Inadmissibilidade - Flagrante lícito - Natureza permanente do crime de tráfico de drogas - Justa e prévia causa demonstrada - Preliminar afastada. Tráfico de Drogas - Insuficiência probatória - Absolvição - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Condenação mantida. Segunda fase da dosimetria - Reincidência específica não possui tanto desvalor a ensejar maior incremento da pena - Majoração da reprimenda em um sexto. (TJSP; Apelação Criminal 1502516-26.2020.8.26.0548; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2022; Data de Registro: 20/06/2022)

2.2. Mérito

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 06/09), do auto de exibição e apreensão (fls. 10/11[AEA] e 12/13 [imagem]) e dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 15/17) e definitivo (fls. 130/134 [LPTox]).

A autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte. A testemunha JESIMIEL DOS SANTOS declarou em sede policial: "que estavam empatrolhamento pelo local dos fatos, onde consta inclusive informações de se tratar de um ponto de comercialização de drogas, ocasião em que avistaram o indiciado PABLO, momento em que, este, ao avistarem a viatura policial, correu em sentido de sua residência, motivo pelo qual a equipe policial foi ao seu encalço. Já na residência do autor, estava ele na sala junto de sua esposa. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, contudo, no armário localizado na cozinha do imóvel, logrou-se localizar 1 (uma) porção média de maconha e outras 7 (sete) porções de cocaína, estas já fracionadas, ressaltando que uma delas era um pouco maior possibilitando ainda o fracionamento. Informam que no mesmo armário foi localizada uma balança de precisão, uma tesoura e diversos "sacólés" de plásticos comumente utilizados para fracionar drogas. Ressalta que em posse da esposa do autor, de nome BEATRIZ, foi localizado a quantia de R\$ 386,00 estando os valores em seus seios, contudo, entregue voluntariamente por ela. Relata que a parte BEATRIZ está com uma criança recém nascida e de colo, sendo por esse motivo justificado que não apresentaram-na ao Plantão. Diante dos fatos, conduziram o autor coercitivamente a esta unidade policial".

Em juízo, além de ratificar suas declarações, informou que no momento da visualização, Pablo estava sozinho. A casa dele possui um portão bem próximo da porta sala - cerca de um metro e um metro e meio; ao entrar, o acusado deixou o portão aberto. A esposa do acusado teria declarado que o valor seria oriundo da prática do tráfico, entretanto não houve registro de suas declarações.

A testemunha JULIO CESAR GUTIERRES BLANCO declarou em sede policial que: "estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, onde consta inclusive informações de se tratar de um ponto de comercialização de drogas, ocasião em que avistaram o indiciado PABLO, momento em que, este, ao visualizar a viatura policial, correu em sentido de sua residência, motivo pelo qual a equipe policial foi ao seu encalço. Já na residência do autor, estava ele na sala junto de sua esposa. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, contudo, no armário localizado na cozinha do imóvel, logrou-se localizar 1 (uma) porção média de maconha e outras 7 (sete) porções de cocaína, estas já fracionadas, ressaltando que uma delas era um pouco maior possibilitando ainda o fracionamento. Informam que no mesmo armário foi localizada uma balança de precisão, uma tesoura e diversos "sacólés" de plásticos comumente utilizados para fracionar drogas. Ressalta que em posse da esposa do autor, de nome BEATRIZ, foi localizado a quantia de R\$ 386,00 estando os valores em seus seios, contudo, entregue voluntariamente por ela. Relata que a parte BEATRIZ

está com uma criança recém nascida e de colo, sendo por esse motivo justificado que não apresentaram-na ao Plantão. Diante dos fatos, conduziram o autor coercitivamente a esta unidade policial"

Em juízo, além de ratificar suas declarações, afirmou que o acusado foi abordado na porta da sala, cerca de 1 metro do portão da entrada. A porta da sala e o portão estavam abertos. Havia denúncias de transeuntes e pelo 190 de que o acusado estaria praticando o tráfico de drogas, sendo inclusive antigas. Quando a viatura virou a rua havia mais gente com o Pablo. Correu por cerca de 15 a 20 metros, sendo que os demais não correram. Foi abordado na porta da sala, ainda não estava na sala. Pablo autorizou o ingresso na entrada. Ninguém havia informado sobre autorização - necessidade de formalização.

A informante Beatriz da Silva Felipe, companheira do acusado, declarou em juízo que no dia dos fatos, Pablo desceu na esquina para fumar, pois não aceita que ele fume em casa em razão de seu filho. Passado certo tempo ele voltou, dizendo que os policiais estavam subindo. Cerca de cinco minutos depois, os policiais chegaram. Pablo mostrou a droga que havia em casa, apenas maconha e o dinheiro que ele tinha recebido em virtude de seu trabalho, as outras coisas ficou sabendo depois no jornal. Os saquinhos eram seus, pois vende geladinho. Não acompanhou a revista dos policiais, não deixaram ninguém acompanhar. O portão da casa estava fechado, os policiais militares que abriram, sem autorização.

O informante Ismael Francisco Machado declarou em juízo que Pablo prestava serviços em seu favela quando dos fatos. Ganhava cerca de R\$ 80 reais por dia. Era um bom profissional.

O acusado Pablo Luan Moreira, por sua vez, ao ser ouvido em juízo, negou a prática do delito. Apenas a maconha apreendida era de sua propriedade e para seu consumo pessoal. Desconhece a origem da cocaína. O dinheiro apreendido era fruto de seu trabalho.

Pois bem. Respeitada a versão do acusado, entendo que, confrontada com o quadro de provas produzido, está absolutamente isolada e contraposta, de modo que as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo para desacreditá-las, penso.

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, guardava (guardar para si) para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas (AEA [individualizadas // ao lado de apetrechos comumente utilizados para o respectivo acondicionamento]), indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" (TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 - Rel. Des. JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN, V.U., j. 17/06/2019), de modo que, no presente caso dos autos, as drogas apreendidas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense, são incompatíveis com a hipótese de simples uso. Vale registrar, ainda, que a redação do art. 33, caput, da LD - tipo penal denunciado e processado - não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário, referendado inclusive pela jurisprudência (STF - 1ª Turma - HC n. 69.806/GO - Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ, Seção I, 04/06/1993; TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 - Rel. Des. PAULO ROSSI, V.U., j. 20/06/2011; TJGO - ACrim. n. 33578- 9/213 - Rel. Des. JAMIL PEREIRA DE MACEDO, DJGO 11/11/2008; RT 729/542 e 114/357), que, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, se faz necessária a intenção de comercializar drogas ilícitas (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), não dependendo, todavia, da exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio.

De rigor a condenação do acusado. Eis o meu convencimento.

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa resultados normativo e

naturalístico nexo de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados, é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3. Dosimetria

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), com preponderância deste em relação àquele; (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente, (iii) a quantidade das drogas, (iv) os antecedentes e (v) as circunstâncias do crime não são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base em seu mínimo legal.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré era menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato (art. 65, I, do CP e Súmula 74 do STJ), entretanto, a pena já se encontra em seu patamar mínimo legal.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, reconheço ser a parte ré primária e de bons antecedentes (conforme Folha de Antecedente e Certidões), de um lado, e, por outro, não existe prova suficiente de dedicação às atividades criminosas, nem de integração de organização criminosa (art. 33, § 4º, da LD), de modo que fixo a pena provisória, reduzida de 1/2, em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 dias multa.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 dias multa, cujo valor diário, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, pode ser o aberto.

Realizo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), porquanto: [a] a pena aplicada não é superior a 4 (quatro) anos e o crime doloso não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; [b] o(a) réu(ré) não é reincidente em crime doloso; e [c] as circunstâncias judiciais indicam que a substituição é suficiente (na medida em que foram todas neutras).

Assim, a substituição, na hipótese deverá ocorrer nos seguintes termos: [a] prestação de serviços à comunidade, na proporção de 1 hora para cada dia de condenação, em instituição a ser indicada na posterior fase de execução (art. 46 do CP); [b] prestação pecuniária em favor da(s) vítima(s), fixada em [1] salários mínimos nacionais vigente(s) na data do fato, corrigido(s) pelo INPC/IBGE a partir de então (art. 45, § 1º, do CP).

Face à substituição, prejudicada eventual análise de suspensão condicional da pena. Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, DESNECESSÁRIA a imposição de prisão à parte ré, que, observadas as medidas cautelares impostas, poderá apelar em liberdade (art. 59 da LD), porque respondeu ao processo solta e não se vislumbra alteração das circunstâncias fáticas.

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos valores apreendidos com a parte ré (AEA), dado que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), constituem proveito auferido com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Com o trânsito em julgado (art. 481 das NSCGJ), oficiase, com os dados processuais, ao Posto de Atendimento do Banco do Brasil para que o(a) agente responsável transfira, por GRU, os valores, com os acréscimos legais, para o Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD (CNPJ 02.645.310/0001-99 - Favorecida UG 200246 - Gestão 0001 - Código 20201-0), cujo comprovante da transferência deverá ser encaminhado e, observadas as disposições normativas, juntado nos autos.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré Pablo Luan Moreira, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º (Comunicado CGJ SP n. 121/2017), às penas de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 dias multa, cujo valor diário determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em a] prestação de serviços à comunidade, na proporção de 1 hora para cada dia de condenação, em instituição a ser indicada na posterior fase de execução (art. 46 do CP); [b] prestação pecuniária em favor da(s) vítima(s), fixada em [1] salários mínimos nacionais vigente(s).

Expeça-se, com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva em desfavor da parte ré (art. 472, I, das NJCGJ).

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, observado o disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional), se o caso.

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publicada em audiência (art. 389 do CPP). Intimadas as partes em audiência (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Tupã, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA